



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 198/11

הנתבעים:

עדה שמיר-אורביטו

גבריאל אורביטו

ע"י ב"כ עו"ד ע. אורביטו

- נ ג ד -

הנתבעים:

אברהם שאלתיאל

דוד מלכה

ע"י ב"כ עו"ד ד. אמסל

פ ס ק - ד י ן

המדובר בבית המשותף ברחוב בן לברט 8 בירושלים המצוי במקרקעין בגוש 30025 חלקה 171 (להלן: "הבית המשותף"). ענייננו של פסק הדין, בדרישת התובעים ליתן כנגד הנתבעים צווי עשה הנוגעים לאופן השימוש בגג הבית המשותף, ולפעולות שונות שעל הנתבעים לבצע או לחדול מלבצע בגג הבית המשותף ובקירותיו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר, כאמור, בבית המשותף בגוש 30025 חלקה 171 בירושלים. בבית המשותף, כך על פי נסח הרישום, 8 תתי חלקות. התובעים הינם בעלי הזכויות בדירה מס' 6, והנתבעים הינם בעלי הזכויות בדירות 1 ו-8 (יוער כי לטובת הנתבעים רשומות הערות אזהרה בלבד, אך במסגרת ההליך הובהר כי הם המחזיקים בדירה, וכי הליך המכר בינם לבין הבעלים הרשום הושלם, אך טרם נרשם. כן יוער כי לנתבע מס' 1 זכויות בדירה נוספת בבית המשותף).
2. דירה מס' 1 מצויה בקומת הקרקע ומוגדרת כ"מוסך". דירה מס' 6, דירת התובעים, מצויה בקומה הראשונה, ומעליה חלק מגג הבית המשותף המסומן בתשריט הבית המשותף בספרה "7" (להלן: "הגג התחתון/הגג"). דירה מס' 8 מצויה בקומה השנייה בבית המשותף (להלן גם: "הדירה העליונה"), ומעליה מצוי "הגג העליון" המסומן בתשריט הבית המשותף בספרה "8" (להלן: "הגג העליון").
3. בצו הבית המשותף הוצמדו שני הגגות (התחתון והעליון) לדירה מס' 1.
4. לגג התחתון ניתן להגיע גם מתוך דירה מס' 8, והנתבעים, שהינם, כאמור, בעלי זכויות הן בדירה מס' 1 והן בדירה מס' 8, משתמשים בגג כבמרפסת היוצאת מדירה מס' 8. המחלוקת בין הצדדים עוסקת, ברובה, בשימוש המבוצע בגג זה על ידי הנתבעים.
5. בתביעתם, טענו התובעים כי יש לאסור על הנתבעים מלהשתמש בגג כבמרפסת, משום ששימוש כזה גורם להם למטרדים רבים, ועלול להביא גם לנזקים לא מבוטלים. בנוסף טענו התובעים, כי הנתבעים משתמשים שלא כדין ברכוש המשותף הסובב את הגג, ומזיקים לו.
6. הנתבעים מצדם טענו, כי זוהי זכותם הקניינית להשתמש בגג שהוצמד להם, וכי אין בפעולותיהם כדי לגרום נזק או מטרד.
7. כבר מלכתחילה נאמר לתובעים, כי ספק רב האם תובענה זו מצויה במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין, שכן לכאורה התביעה עוסקת ברובה בסוגיות הנוגעות לדיני המטרדים. דא עקא, שהתובעים עמדו על בירור התובענה בפניי, וטענו כי במהלך ההליך יוכח, כי נושא הדיון הוא פגיעה ברכוש המשותף ובשטחי הבית המשותף. בעקבות זאת, נקבע התיק לתצהירים, ועדי הצדדים נשמעו בימים 29.4.12 ו-17.10.12.
8. לאחר תום שמיעת הראיות הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. טענות התובעים בקצרה:

9. טענתם העיקרית של התובעים היא, כי על אף שהגג שייך לנתבעים (מאחר שהוא הוצמד לתת חלקה 1), אין לנתבעים זכות לעשות בו שימוש כבמרפסת. בהקשר לטענה זו נטען על ידי התובעים, כי הגג הוצמד לדירה בקומת הקרקע ולא לדירה מס' 8, וכי ההצמדה הוגדרה כ"גג" ולא כ"מרפסת" או "מרפסת גג". כן מפנים התובעים לכך שקיימת כניסה לגג מחדר המדרגות, ולכך שהגג אינו במפלס דירת התובעים העליונה, אלא יש לעלות מדרגה כדי להגיע אליו. לשיטת התובעים עובדות אלו מעידות על כך כי הכוונה היתה לשמור על צביון הגג כ"גג", ועל כך, מנועים הנתבעים מלהשתמש בו כ"במרפסת גג", לערוך בו מסיבות וכיוצא באלו, או להציב בו רהיטים.
10. יתרה מכך, כך מסבירים התובעים, אף לו היה מוגדר הגג כמרפסת גג, לא היה בכך כדי לאפשר לנתבעים לבצע בו את השימושים אותם הם מבצעים. לטענת התובעים, הנתבעים משתמשים בגג כ"מעין אולם ריקודים ומסיבות קולניות", ופעולות אלו חורגות באופן בוטה ממתחם הפעולות הסבירות שניתן לבצע במרפסת המצויה בבית משותף. בתוך כך, מלינים התובעים על כך הנתבעים ערכו מסיבת רבת משתתפים ביום העצמאות, אליה הוזמנו לא פחות מ- 1,787 איש. לטענת התובעים מדובר בהפרעה חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת בבית משותף, וחמור מכך, כך לדבריהם, ביצוע מסיבה כזו בהיעדרם של מתקני תברואה ואישורים שונים, והנחת חפצים כבדי משקל על הגג, גרמו למטרדים חמורים ביותר לכלל בעלי הדירות בבית המשותף, ועלולים היו להביא חלילה לקריסת הגג.
11. בסיכומיהם, מפנים התובעים לפסק הדין בע"א 2126/02 גאסן נ' רגב, (ניתן ביום 20.7.04, פורסם באתר נבו), לפסק הדין בתיק (מפקח ת"א) 260/10 מורן נ' לוי, (ניתן ביום 6.10.10, פורסם באתר נבו), ולפסק הדין בתיק (מפקח ת"א) 112/11 נציגות הבית המשותף נ' חדד דוד, (ניתן ביום 15.1.12, פורסם באתר פסק דין), מהם מבקשים ללמוד כי גג הבית המשותף לא נועד לשמש כמרפסת, או כמקום עריכת מסיבות ומשחקים.
12. התובעים מוסיפים גם, כי מלכתחילה לא ניתן היה להצמיד את הגג ל"מוסך", שכן הגג הוא רכוש משותף, ומשהוצמד יש לצמצם את הפגיעה ביתר בעלי הדירות.
13. מוסיפים התובעים וטוענים, כי הנתבעים בנו מעקות עץ על גבי מעקות הגג, שהינם רכוש משותף, ללא קבלת ההסכמות הדרושות בחוק. בנוסף, כך לטענת התובעים, בנו הנתבעים פרגולה על גג הבית המשותף. לטענת התובעים, פעולות אלו מהוות פגיעה בחזונו של הבית המשותף, ולפיכך היה על הנתבעים לקבל את הסכמת בעלי הדירות, כתנאי לביצוען. בהקשר למעקות שנבנו, טוענים התובעים כי יש לסלקם כדי למנוע מהנתבעים להפוך את הגג למתחם מסיבות המוניות, שאין כל מקום לקיימן בבית משותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

14. התובעים טוענים עוד, כי הנתבעים בנו גגון מעל דלת היציאה לגג, והגדילו חלון בצידו המזרחי של הבית המשותף. לטענת התובעים גם פעולות אלו משנות את חזונו של הבית המשותף, והנתבעים לא היו רשאים לבצען ללא שקיבלו את הסכמת בעלי הדירות.
15. התובעים מוסיפים, כי הנתבעים ביצעו, ללא שקיבלו הסכמה לכך, קידוחים ונקודות חשמל בגג ובמעקותיו, ובכך גם גרמו נזק לגג. בתוך כך, התובעים מפנים, בין היתר, לחקירתו הנגדית של הנתבע מס' 1, ומבקשים ללמוד מדבריו כי הוא אישר שהמומחה אילוז קבע כי ייתכן מאוד שחלק מגורמי הרטיבות בדירת התובעים קשורים לדירת הנתבעים ולעבודות שביצעו. יחד עם האמור, מבהירים התובעים בסיכומיהם, כי אין הם תובעים במסגרת תביעה זו בגין נזקי הרטיבות הנטענים, וכי הם מבקשים לבחון נושא זה במשך תקופת החורף.
16. כן טוענים התובעים, כי הנתבעים מציבים בגג, שלא כדין, מתקנים כבדים וריהוט מאסיבי, וכי המשך הצבתם, כמו גם החזקה ושימוש לא נכונים בגג, ימשיכו לגרום לרטיבות לדירתם, ועלולים אף להביא לפגיעה בבית המשותף, בגג, וביציבותו.
17. לטענת התובעים, פעולות הבניה שביצעו הנתבעים בגג מהוות חסגת גבול כמשמעותה בסעיף 29 לפקודת הנזיקין, הפרת חובה חקוקה, מטרד ליחיד ומטרד לציבור, כהגדרתם בסעיפים 42-44 לפקודת הנזיקין. בנוסף, כך לטענת התובעים, פעולות הנתבעים מגיעות עד כדי עבירה על סעיף 53 לחוק עזר ירושלים (שמירת הסדר והניקיון), תשל"ח-1978. כן נטען על ידי התובעים, כי פעולות הנתבעים הינן בניגוד לסעיף 14 לחוק המקרקעין, ובניגוד לסעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי שבחוק. התובעים מוסיפים גם, כי פעולות הנתבעים פוגעים בזכותם הקניינית ומנוגדים בשל כך לחוק היסוד.
18. בסיכומיהם, מתייחסים התובעים גם לתקנה 3(ב) לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992, וטוענים כי יש לבטלה בהיותה סותרת את החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. לכל הפחות, כך לשיטתם, יש לפרשה בצמצום רב, ולכן יש לקבוע כי ההחרגה הקיימת בתקנות הנ"ל, לא תחול בבית משותף בתוך שכונת מגורים, שחלות עליו הוראות התקנון המצוי.
19. התובעים סבורים גם, כי יש לאסור על הנתבעים לעשות "מנגל" על הגג, שכן הדבר מהווה סכנה למעקות הגג שעלולים לבעור. כן טוענים התובעים בסיכומיהם, כי הדבר "עלול להיות תקיפה לפי סעיף 378 לחוק העונשין, תשל"ז-1977", והוא אף עומד בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

20. בסיכומיהם מסבירים התובעים, כי קשה מאוד ליתן סעד אופרטיבי המכמת ומגדיר את הפעולות שהתובעים רשאים לבצע בגג, ודורשים, על כן, כי יינתן צו המורה להם שלא לשהות בגג מעבר לזמן הדרוש לצורך תחזוקת הגג. לשיטתם, צו זה דרוש לאור התנהלות הנתבעים במשך השנים. כן מסבירים התובעים, כי הם מודעים לכך שחלק מהסעדים הנדרשים אינם בסמכות המפקח על רישום המקרקעין, אך הם נגררים לתביעה העיקרית המצויה בסמכותו של המפקח.
21. חלק ניכר מסיכומיהם, מקדישים התובעים כדי לבסס את טענתם שלפיה הנתבעים נמצאו בלתי אמינים, ואף כשלו בביצוע עבירות על החוק. כן מקדישים התובעים בסיכומיהם פרק מיוחד לעניין הוצאות המשפט, במסגרתו מפנים גם להליכי הביניים בהליך זה, ולהוצאות שנפסקו במסגרתם.
22. בסיכומי התשובה חוזרים התובעים על טענותיהם כנגד הנתבעים, ומוסיפים כי הנתבעים צרפו לסיכומיהם ראיות שלא כדין. בהקשר לכך מבקשים התובעים, כי אורה על מחיקת סעיפים 31,35,36,46 לסיכומי הנתבעים העוסקים בהצבת בלוני הגז ובתיקון הנדרש באיטום הגג. כן מבקש במסגרת סיכומי התשובה, כי אורה על מחיקת הטענות בסיכומי הנתבעים הנוגעים לטענת הנתבעים שלפיה התובעים מונעים מהם את מימוש זכויות הבניה בגג בחוסר תום לב. בסיכומי התשובה טוענים התובעים גם כי יש לבכר את חוות הדעת שהוגשו מטעמם, על פני אמירות בעלמא של הנתבעים.
23. לאור כל האמור מבקשים התובעים, כי יינתן צו המצהיר, כי הגג אינו יכול לשמש כמרפסת גג, ולפיכך, נאסר על הנתבעים להשתמש בגג כמגרש משחקים או מקום אירוח, ונאסר על הנתבעים לשהות בגג מעבר לנדרש לתחזוקתו. כן מבקשים התובעים כי אורה כי אין לבנות על הגג בניה כלשהי, בין בניית קבע בין בניית ארעי, ובכלל זה, סוכה ופרגולה, וכן אורה כי הנתבעים מנועים מלרצף את הגג בכל צורה שהיא. התובעים מבקשים גם, כי יינתן צו האוסר על הנתבעים להתקין מעקות על גג הבית המשותף, ומורה להם להסיר את התאורה שהותקנה מעל פתח היציאה לגג, וכן כל חפץ שהציבו בגג. כן דורשים התובעים, כי יינתן צו האוסר על הנתבעים להניח בגג חפצים מכל סוג. בנוסף מבקשים התובעים כי יינתן צו האוסר על הנתבעים לשנות את קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, לרבות הפתחים מתוך חדר המדרגות לתוך הגג. התובעים מבקשים גם, כי יינתן צו המורה לנתבעים לתחזק את הגג באופן שוטף על מנת למנוע רטיבות בדירתם, ולחייבם לבצע בדיקת הצפה על מנת לוודא שאכן קיים איטום ראוי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. טענות הנתבעים בקצרה:

24. לטענת הנתבעים, הגדרת "מרפסת גג", הינה הגדרה הקשורה לדיני התכנון והבניה, והמפקח על רישום המקרקעין כלל אינו מוסמך לדון בכך. בכל מקרה, כך לשיטתם של הנתבעים, אין בטענה ממש גם לגופה, שכן אין כל הבחנה בין אופן בניית מרפסת לאופן בניית גג. הנתבעים מפנים בהקשר לטענה זו לעובדה שקיימות דירות גג רבות, ואף כאלו ששטחן קטן משטח מרפסת הגג הצמודה להן.
25. לשיטת הנתבעים, מאחר שהגג בבעלותם, הרי שהם רשאים לעשות בו כאוות נפשם, בכפוף לכך שפעולותיהם אינן נוגדות את החוק, ואינן מהוות מטרד לשכניהם. לטענת הנתבעים, לא הוכחה כל פגיעה בשכנים ולא הוכחה עבירה כלשהי על החוק.
26. הנתבעים מוסיפים, כי התובעים לא הביאו הוכחה או אסמכתא לטענתם שלפיה אסור להם לרצף את הגג. כן טוענים הנתבעים כי הגבהת המעקות נועדה כדי ליצור מעקה תקני, וזאת על מנת למנוע סכנה בטיחותית. בעניין זה מוסיפים הנתבעים, כי אין כל ממש בטענת התובעים שלפיה יש במעקות כדי לפגוע בחזות הבית המשותף. כן טוענים התובעים בעניין זה, כי הוכח שאין כל צורך בקבלת היתר להגבהת המעקות.
27. בכל הנוגע לטענת התובעים בעניין הפרגולה, נטען על ידי הנתבעים כי לא הוכח שקיימת פרגולה במקום, ובכל מקרה יש לדחות סעד של הריסה ביחס לפרגולה, שכן סעד זה לא נתבע בכתב התביעה.
28. במסגרת סיכומיהם, מצהירים הנתבעים כי הם אינם מתכוונים לבצע בגג פעולה כלשהי שאינה סבירה, תוך שהם מדגישים בסיכומיהם, כי אין בכוונתם להפוך את המקום ל"אולם ריקודים קולני". הנתבעים מפנים גם לעדותם בדיון, שלפיה נערכה במקום רק מסיבה אחת, ביום העצמאות, אליה הזמנו רק חבריו של הנתבע. הנתבעים מוסיפים ומדגישים, כי לכל אורך הדרך הם הבהירו כי אין להם התנגדות למתן צו המגביל באופן סביר את השימוש בגג, אך בשום אופן אין לקבל את טענת התובעים, שלפיה שימוש סביר בגג מהווה אך ורק שימוש לצורך תחזוקתו. לשיטתם, זו זכותם הקניינית לשהות בגג שבבעלותם, ואין כל מקום לדרישה זו של התובעים.
29. התובעים מודיעים, כי אין הם מתכוונים לבצע שינוי בקירות החיצוניים של הבית המשותף, לרבות שינוי הפתחים מתוך חדר המדרגות, אלא בכפוף לקבלת היתר בניה ולאחר שיקבלו את אישור בעלי הדירות בבית המשותף. אשר לדרישת התובעים להסרת התאורה בגג, מסבירים הנתבעים כי אין כל מקור חוקי לדרישה זו, וכי אף לשיטת התובעים הם נדרשים לתחזק את הגג, וממילא נדרשים הם להצבת תאורה זו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

30. לטענת הנתבעים, טענות התובעים בדבר פגיעה ביציבות המבנה או באטימותו כתוצאה מהצבת ריהוט, נטענו בעלמא, ללא צירוף של חוות דעת כדבעי התומכת בכך. בהקשר לכך טוענים הנתבעים גם, כי טענות התובעים לרטיבות בדירתם שמקורה בגג הבית, לא נתמכו בחוות דעת של ממש, ובכל מקרה אין לכך רלוונטיות לענייננו, שכן לכל אורך תביעתם וסיכומיהם הסבירו התובעים, כי אין להם דרישה, במסגרת תביעה זו, לתיקון רטיבות או לקבלת פיצוי נזיקי בגין נזקי רטיבות.
31. אשר לתחזוקת הגג, נטען על ידי הנתבעים כי התובעים לא פרטו מה התחזוקה הנדרשת, ולא צרפו חוות דעת כלשהי שיש בה כדי להוכיח כי התחזוקה כיום אינה מבוצעת כראוי. בעניין זה מלינים הנתבעים גם על כי התובעים לא פרטו מה הסעד המדויק הנדרש, והסתפקו באמירות כוללניות.
32. במסגרת סיכומיהם קובלים הנתבעים גם על דרישות נוספות שהעלו התובעים, על סגנונם, ועל התנהלותם שלא על פי סדרי הדין המקובלים, ודורשים הוצאות ספציפיות בגין דרישות אלו. בהקשר לכך מוסיפים הנתבעים גם, כי אין בלוגי גז על הגג, וממילא לא היה מקום לטענות התובעים בעניין זה.
33. בכל הנוגע לטענות התובעים בעניין העשן והלכלוך העולה מעישון סיגריות, טוענים הנתבעים כי מדובר בטענה מופרכת לחלוטין שלא נתמכה בראיה כלשהי. מכל מקום, כך לשיטת הנתבעים, אין חוק האוסר על הנתבעים לעשן בשטחים שבבעלותם. באופן דומה מסבירים הנתבעים, כי אין כל צידוק למנוע מהם מלעשות "מנגל" על הגג שבבעלותם.
34. אשר לטענות התובעים בדבר ירידת ערך הבתים בבית המשותף, נטען על ידי הנתבעים, כי הדבר אינו מצוי במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין, ובכל מקרה התובעים לא הציגו ולו ראשית ראיה לנושא זה. לשיטת הנתבעים, דווקא התובעים, בפעולותיהם, הם שמביאים לירידת ערך הדירות בבית המשותף.
35. הנתבעים מפנים לכך שהתובעים עצמם סברו, כי חלק מהעילות והסעדים המבוקשים בתביעה אינם בסמכות המפקח על רישום המקרקעין, ובכל זאת דרשו להותיר את התביעה על כנה. לשיטתם יש להביא זאת בחשבון בפסיקת ההוצאות.
36. הנתבעים טוענים, כי יש לדחות את טענות התובעים בעניין מטרד גם לגופו של עניין, נוכח העובדה שלא הוצגה כל ראיה לכך, והדבר נטען לראשונה בסיכומי התובעים. טענות דומות טוענים הנתבעים ביחס לאמור בסיכומי התובעים בקשר לחוק עזר ירושלים (שמירת הסדר והניקיון), לתקנות הרעש, לעבירת התקיפה ולתקנות למניעת מפגעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

37. לאור כל האמור מבקשים התובעים להורות על דחיית התביעה תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט, אשר ישקפו גם את התנהלותם לאורך כל ההליך כולו.

ד. דיון והכרעה:

38. שלושה נושאים עיקריים בתביעה: הראשון, והוא העיקרי מבין השלושה, עוסק בדרישות התובעים להגדרת השימוש המותר בגג (טענות התובעים בעניין עישון, בישול בגג, עריכת מסיבות, שימוש בגג כגן משחקים, וכיוצא באלו). השני, נוגע לטענות התובעים ביחס לשינוי חזית הבית המשותף (בניית מעקות, בניית פרגולה, ופתיחת פתחים), והשלישי, עוסק בטענות התובעים לפגיעה פיזית בבית המשותף באמצעות הנחת מתקנים וחפצים שונים, ריצוף הגג, ובנייה על הגג.

39. לאחר ששמעתי את כלל הראיות, טענות הצדדים וסיכומיהם, אין לי אלא להצטרף על כי התובעים התעקשו לנהל הליך זה בפניי, שכן כפי שיוסבר להלן, עיקרה של התביעה (אופי השימוש בגג), אינו במסגרת סמכותי העניינית, הקבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק או חוק המקרקעין").

40. על מנת להבהיר את האמור אקדים הקדמה קצרה. להווי ידוע, כי כפי שנקבע בסעיף 52 לחוק, בבית משותף קיימים שני רכיבים השונים מהותית זה מזה: "דירות" ו"רכוש משותף" [ר' למשל: א. דויטש, קניין, כרך א', 657]. בנוסף, בעלי הדירות רשאים (ברוב הדרוש בחוק בהתאם לעניין), להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה ספציפית, ובמקרה כזה, נקבע בסעיף 55(ג) לחוק כי: "הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".

41. ההבדל העקרוני הבסיסי בין הרכוש המשותף לדירה הוא, שבעוד ש"דירה" (והחלק המסוים שצמוד אליה) מהווה, כך על פי סעיף 54 לחוק, נושא נפרד לבעלות, הרי שהרכוש המשותף שייך באופן בלתי מסוים לכל בעלי הדירות.

42. בבואנו לבחון את היקף זכות השימוש של בעל דירה בדירתו וברכוש המשותף הכללי, עלינו להבחין אפוא, הבחן היטב, בין שימוש שמבקש בעל דירה לבצע ברכוש המשותף, לבין שימוש שמבקש בעל דירה לעשות בדירתו, ובכלל זה בחלק שהוצמד לו לפי סעיף 55(ג) לחוק.

43. בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע, כי היקף זכותו של בעל דירה ברכוש המשותף, וכנגזרת, היקף השימושים שהוא רשאי לבצע ברכוש המשותף, נבחנים במשקפי "סבירות



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

השימוש", וזאת, בין היתר בהתחשב בהוראה הקבועה בסעיף 31 לחוק המקרקעין העוסק בשותפות במקרקעין. כך למשל נקבע בע"א 549/73 וינטרס נ. זמורה, פד"י, כח (1) 645, כי כל בעל דירה זכאי לבצע ברכוש המשותף שימוש סביר ורגיל, ואילו לביצוע פעולות החורגות מכך, יידרש הוא להסכמת הרוב הקבוע בחוק. בהינתן זאת, נקבע בפסקי דין רבים (שלחלקם הפנו התובעים בסיכומיהם), כי בגג שהוא רכוש משותף, זכאי בעל דירה לבצע רק שימוש סביר, היינו, שימוש שאינו מהווה חזקה ייחודית, ואינו משנה את אופיו של הרכוש המשותף.

לעומת זאת, היקף השימוש שבעל דירה רשאי לעשות בדירתו אינו מוגדר (מבחינת הזכות הקניינית) באמצעות "סבירות השימוש", אלא הוא כפוף, ככל שהדבר נוגע להוראות חוק המקרקעין, לסעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי שבחוק, בהם נקבע כך:

- (א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
- (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
- (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו. (ההדגשות לא במקור).

על פי הוראות אלו, אין בעל דירה מוגבל ביחס לזכותו בדירתו, ובלבד שלא יבצע בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או ברכוש המשותף, או משנים את ערכו. ודוק: בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח', פ"ד כ"ח (1) עמ' 730, נקבעה ההלכה שלפיה שינויים ותיקונים בדירה לענין סעיף 2 לתקנון המצוי, הינם שינויים פיזיים בגוף הדירה שבעטיים ניזקה דירה אחרת או הרכוש המשותף, ואילו שינוי שעניינו אופן השימוש בדירה, אינו נופל בגדר הסעיף. כך הבהיר זאת בית המשפט העליון בפסק דין שמע נ' סדובסקי הנ"ל:

"...אף אני אין אני כופר בכך שלא רק שינוי המבנה שעשה דייר על דעת עצמו, אלא גם שינוי במטרה אשר לה הועדה דירה (שינוי שימוש) עלול לפגוע ברכוש השותפים, או לסכן את קיומו או לשנות את ערכו, כאמור בסעיף 2 לתקנון. אך לא זו השאלה הצריכה להכרעה. השאלה היא, אם עשה הנתבע, על-ידי שהפך את דירתו לבית-עסק, "בדירתו שינויים או תיקונים", מלבד אותם שינויים במבנה שכבר אינם עומדים לדיון. דעתי היא, שהשינוי בשימוש שנעשה אינו בגדר שינוי בדירה, כמשמעותו בסעיף 2 לתקנון... כללו של דבר: שינויים בדירה לענין סעיף 2 לתקנון אינם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שינויים בתוך הדירה, בשימוש שגעשה בה, אלא הם שינויים בגוף הדירה שבעטיים ניזקה דירה אחרת או הרכוש המשותף. (ההדגשה לא במקור).

46. במסגרת הדיון הנוסף הנ"ל, עמד בית המשפט העליון גם על ההבחנה בין היקף הזכות הקניינית שיש לבעל דירה ברכוש המשותף לבין זכותו בדירתו, וקבע כדלהלן:

"...תמים דעים אני עם בית-המשפט המחוזי, שלצורך פרשנות הסעיף 2 הנ"ל חייב לשמש לנו מורה-דרך הרעיון המונח ביסודו של בית-משותף. רעיון זה בא על ביטוי בסעיף 54 לחוק המקרקעין, המורה כי דירה בבית משותף יכול שתהא נושא לבעלות נפרדת. בזה משתנה בית משותף ממקרקעין אחרים, אשר בהם, על-פי סעיף 13 לאותו חוק, לא תיתכן זכות בחלק מסויים של הנכס. משנתן המחוקק היתר ליצירת קניין נפרד בחלק מסויים של בית. קם הצורך להסדיר את היחסים בין השותפים, ולכך משמש התקנון. אבל השותפות בין הדיירים היא שותפות בקניין, והזכויות והחובות הנובעות ממנה אינן אלא כזכויות וחובות של בעלים כשהן מותאמות לצרכי השותפות. זכויות הקניין בבית משותף הן מקצתן נפרדות, ומקצת משותפות. לגבי דירתו בבית משותף נוהג השותף כבתוך שלו, ואין דינו שונה מדין בעליו של בית אחר..." (ההדגשות לא במקור)

ומהי, בכל זאת, תרופתו של בעל דירה הטוען לפגיעה ממעשיו של שכנו, שאינם בגדר שינוי במובנו של סעיף 2 לתקנון המצוי? גם לכך התייחס בית המשפט העליון בפסק הדין הנ"ל והבהיר כי:

"...לגבי דירתו גופה אין לו לבעל הדירה שותפים, ולענין זה כולם כפופים להלכות הדין הכללי. דיני הנזיקין מונעים קיומו של מטרד, וכדרך שמי שאינו בעל דירה בבית משותף מוגן על-ידיהם מפני מטרד, כך גם הבעלים בינם לבין עצמם. דיני בתים משותפים אינם מוסיפים לדיני נזיקין ואינם גורעים מהם... מפני עיסוק השכן בתוך דירתו, בין אם עסק בו מלכתחילה ובין אם עשה כן לאחר מכן, מוגן בעל דירה על-ידי פקודת הנזיקין, ואילו סעיף 2 (א) לתקנון בא להבטיח את שלמותו של המבנה ותקינותו... למותר להוסיף שככל אדם אחר יכול גם בעל דירה בבית משותף לתבוע בעל דירה אחרת לא רק בעילה של מטרד, אלא גם בעילה אחרת, כגון בניה לא-חוקית, אפילו אינה מגיעה לכדי מטרד, לפי ההלכה שנפסקה בבית-משפט זה, ראה ע"א 25/66, [7], וזכות הקניין בדירת הנתבע אינה משמשת הגנה מפני תביעה שכזאת. יתר-על-כן, בעל דירה החפץ לחייב בעלי דירות אחרות להועיד זירותיהם לשימוש מסויים בלבד, כגון למטרת מגורים, יכול לקבוע כך בתקנון מוסכם שייערך על-פי סעיף 62 לחוק המקרקעין. ואולם באין תקנון מוסכם, חל התקנון המצוי, וההוראות שבו מגינות על זכות הקניין של בעלי הדירות ותו לא." (ההדגשה לא במקור).

48. הנה כי כן, בעל דירה אינו יכול לטעון כנגד שכנו, כי מכח חוק המקרקעין, הוא רשאי לבצע בדירתו רק "פעולות סבירות" (שלא כפי שרשאי הוא לטעון כנגדו ביחס לרכוש המשותף), וככל שהוא מבקש להלין על פעולות שמבצע חברו בדירתו המטרידות אותו, שאין בהם פגיעה במובנו של סעיף 2 לתקנון, עליו להגיש תביעה המעוגנת בדין הכללי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

49. דא עקא, שתביעה שכזו של בעל דירה היונקת מדיני הנזיקין והמטרדים, אינה מצויה בד' אמותיו של המפקח על רישום המקרקעין, שכן סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין תוחמה וצומצמה לעילות המפורשות בסעיף 72 לחוק. כך למשל נקבע בד"נ שמע נ' סידובסקי הנ"ל: "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך ... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". בכלל זאת נקבע, כי גם עילת המטרד אינה בסמכותו של המפקח. (ר' עוד לעניין סמכות המפקח על רישום המקרקעין: ע"א 458/69 שליט נ. גולדברג, פ"ד כד' (1), עמ' 231, ע"א (ת"א) 664/71, עורקבי ואח' נ. נקר, פ"מ כרך עח', עמ' 130, ע"א 3/98, גרינוולד נ. סילוני ואח', פ"מ נח' (2) עמ' 118).

50. על רקע האמור נבחן את התביעה דנן.

51. נקל להבחין, כי התביעה נוגעת, בראש ובראשונה, לעוולת המטרד, כאשר העילה המרכזית העולה ממנה מבוססת על טענות בדבר הפרעה לשימוש במקרקעין הנגרמת לתובעים עקב פעולות הנתבעים. טענותיהם של התובעים בהליך דנן - הינן בדבר פגיעה באיכות החיים, ביכולת השימוש במקרקעין וקיומו של חשש מפני פגיעה, הכל בשל השימוש שעושים הנתבעים בדירתם (ובהצמדות) או עקב התנהגותם של האחרונים. ודוק: טענות אלו נופלות בדיוק לגדרו של סעיף 44 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] הקובע כי "מיטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפוששים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם". כמו כן, מבססים התובעים תביעתם בכל הנוגע לשימושים המבוצעים בגג, על הוראות חוק נוספות, ובכללן, חוק עזר ירושלים (שמירת הסדר והניקיון), תשל"ח-1978, דיני התכנון והבניה, והחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961.

52. נמצא אפוא, כי תביעת התובעים ביחס לשימוש הנתבעים בגג הצמוד לדירתם, אינה שואבת כוחה מהוראות חוק המקרקעין, אלא מהוראות חוק שהדיון בהן אינו מסור למפקח על רישום המקרקעין לפי סעיף 72 לחוק, וממילא אין לי אלא לקבוע כי כל הסעדים המבוקשים על ידי התובעים בכתב התביעה, שעניינם הגדרת אופי השימוש בגג, אינם במסגרת סמכותי העניינית. ויודגש: נושאים אלו כלל לא נדרשים על מנת להכריע בנושאים אחרים בתביעה המסורים לסמכותי, וממילא אין גם מקום לטענות התובעים לסמכות שבגררא.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

53. משהגעתי למסקנה כי התביעה ביחס לשימוש בגג על ידי הנתבעים אינה במסגרת סמכותי העניינית, ונוכח הוראות סעיף 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, התלבטתי האם נכון יהיה להעביר את התביעה לבית המשפט השלום או למחקה. מחד גיסא, בהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט בתל אביב ע"י כב' השופט קלינג בת"א 1098/01 (ת"א) **פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף** תק – מח 2002(2) 3071, משעה שמצא המפקח כי אין לו סמכות לדון בתביעה שבפניו, עליו להעביר התביעה לבית המשפט המוסמך. מאידך גיסא, בהלכה שיצאה מבית המשפט העליון ברע"א 3748/05 **בזק נ' שרת התקשורת** (ניתן ביום 6.5.05, פורסם באתר נבו) נקבע כי: **"הכלל שבסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט הוא שעל בית המשפט להעביר העניין, אך אין מדובר בחובה שאין לסטות ממנה (זוסמן, סדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית), 1995, 89).**" לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, ובכלל זה, את העובדה שמדובר בתביעה שסעדיה בעניין השימוש הינם כוללניים ביותר, את השלב בו מצוי הדיון והעובדה כי נשמעו כבר עדי הצדדים, ובעיקר, את העובדה כי הצדדים הינם, בסופו של דבר, שכנים בבית משותף וראוי ליתן להם הזדמנות נוספת ליישב את ההדורים ביניהם (כאשר יצוין, כי בהליך בפניי אף הצהירו הנתבעים כי הם מסכימים להגביל את השימוש באופן כזה או אחר), הגעתי לכלל מסקנה, כי נכון יהיה למחוק את התביעה ולא להעבירה לבית המשפט השלום. יוסף, כי לתוצאה זו ניתן היה להגיע גם לאור סעיף 75 לחוק המקרקעין, המתיר למפקח על רישום המקרקעין לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין.

54. בבחינת למעלה מהדרוש, ומבלי לקבוע מסמרות, חשוב להוסיף, כי טענת התובעים שלפיה הגג לא הוענק לנתבעים, אלא לצורך תחזוקתו בלבד, מוקשית גם לגופה במידה לא מועטה, וזאת ממספר נימוקים:

55. ראשית, עיון בפסיקה הענפה של בית המשפט העליון בנושא הצמדת הגג מלמד, כי בכל אותם מקרים בהם הוצמד גג לדירה כלשהי, נסב הדיון על השאלה האם הוצמדו גם זכויות הבניה, בעוד שהנחת המוצא היתה כי בעל הזכויות בגג רשאי לנהוג בו מנהג בעלים. כך למשל סוכמה ההלכה בע"א 10322/03 **לביא ישעיהו נ' אליעזר יעקב שטרייכר**, נט (6) 449: **"מה הטעם להצמיד גג ליחידת דיור באין זכות לבנות על הגג? על כך נאמר כי "אין ספק שעצם הצמדת הגג ליחידה מסויימת איננה נותנת לבעל היחידה זכות לבנות על הגג כעולה על רוחו ללא הסכמת בעלי הדירות האחרות בבית, אלא גורמת אך ורק לכך שאותו חלק מהגג חדל להיות חלק מהרכוש המשותף והופך להיות חלק מהדירה..."** (דברי השופט " כהן (כתוארו אז) בע"א 749/76 **יוסף נ' בכר** [9], בעמ' 621; ויסמן [20], בעמ' 424). כן נקבע, כי בסופו של דבר, ההצמדה נועדה להביא לכך שבעל הדירה יהא רשאי להשתמש בשטח ההצמדה כבדירתו, ולפיכך יצירת הבחנה ביחס להיקף



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הזכות רק בשל ה"כינוי" שניתן להצמדה, עלול להביא לעיוות. כך הסביר זאת בית המשפט המחוזי בע"א (י-ס) 190/84 אליצור דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין, פ"ד תשמ"ה(2), 265: "אחרי ככלות הכל יש לזכור שבסיסו ההגיוני של מוסד ההצמדה בחוק נעוץ ברצון לאפשר לבעלי דירה לרכוש זכויות מלאות בחלקי בית הנמצאים מחוץ לדירה, ולא ליצור אנומליה רישומית של מגורים ברכוש משותף שרק כנויו הוא כזה בעוד שמבחינת הזכויות עליו הוא שייך להם ע"י הצמדתו לדירה....".

56. יתרה מכך, נראה, כי התובעים נתפסו לכלל טעות מאחר שהם לא דקו היטב בתשריט הבית המשותף. עיון בתשריט הבית המשותף מלמד, כי הגג מושא המחלוקת דווקא הוגדר כ"מרפסת גג". ברי, כי בכך יש כדי לשמוט את הקרקע תחת טענתם העקרונית של התובעים, שכן לשיטתם יש להבחין בין "גג" לבין "מרפסת גג", ובמקרה דנן, כאמור, הוגדר שטח המחלוקת כ"מרפסת גג". [יצוין, כי בתשריט הבית המשותף ניתן לראות, כי בקומה שסומנה כ"קומת הגג", סמוך לדירה הנתבעים העליונה, דירה 8 (המסומנת בתשריט בספרה 6), מופיע חלק מהגג המוגדר כ"מרפסת גג". יוער, כי חלק זה בתשריט צורף בחלקו כנספח ה' לתביעה, אך עיון בתיק הבית המשותף מלמד כי המסמך שצורף קטוע בחלקו].

57. סיכומו של דבר, שאני מורה על סילוקה של התביעה, בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לשימוש בגג ולהגדרתו, כאשר למותר לציין כי בידי התובעים הזכות להגיש תביעה בעניינים אלו, לבית המשפט המוסמך.

58. עתה אתייחס לשתי הסוגיות הנוספות שבמחלוקת, קרי, סוגיית הפגיעה הנטענת באיטום הבית המשותף וביציבותו, ושאלת השינויים בחזות הבית המשותף. ודוק: בניגוד לשאלת השימוש בגג, הרי שלית מאן דפליג כי שתי סוגיות אלו בהן נחלקו הצדדים, מצויות במסגרת סמכותו השיפוטית של המפקח.

59. טענת התובעים בנוגע לפגיעה ביציבות הבית המשותף ובאיטום הגג, ודרישתם למתן צו כנגד הנתבעים המחייבם בתחזוקה תקינה של הגג:

60. לכל אורך הדרך חזרו והדגישו התובעים, כי אין הם מבקשים במסגרת תביעה זו סעד שקשור לבעיית האיטום, ולנזק שנגרם להם, לטענתם, כתוצאה מליקויים באיטום הגג. בד בבד, הם דרשו לקבוע, כי כל בניה על הגג, תהא אשר תהא, וכל הצבת חפץ כלשהו בגג, ואף ריצופו של הגג, עלול לגרום לנזקים חמורים באיטום הגג וביציבות הבית המשותף, ולפיכך יש לאסור זאת על הנתבעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

61. דא עקא, שהתובעים בחרו שלא להציג חוות דעת מומחה ערוכה כדין בדבר הנזק העלול להיגרם, לא הזמינו לעדות מומחה כלשהו שיעיד על כך, ובחרו להסתפק באמירות כלליות בעלמא.
62. לא זא אף זו, מהמסמך שממנו מבקשים התובעים להיבנות, מכתבו של המהנדס אורן, מוצג ת/1, עולה דווקא כי בעיית האיטום על הגג נפתרה. כמו כן, מהמסמך עולה כי אין כל בעיה ביציבות הגג כתוצאה מפעולות הנתבעים, שכן נעדרת ממנו כל קביעה כי השימוש בגג עלול לפגוע באיטום הגג או ביציבות הבניין. היעדר התייחסותו של המהנדס אורן לפגיעה הנטענת ביציבות הבניין בשל השימוש בגג, מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה שהמהנדס אורן כן התייחס לכך שיש לחזק את קירות התמך מסביב לבניין בשל סחף אדמה (סעיף 9 לת/1).
63. בנסיבות אלו, הרי אין לי אלא לקבוע כי התובעים לא הרימו ולו במעט את הנטל המוטל עליהם כדי להוכיח את הפגיעה הנטענת, ולפיכך דין תביעתם בעניין זה להידחות, כאמור. למען הסדר הטוב יודגש, כי דחיית התביעה נוגעת לטענת התובעים, שלפיה כל בניה בגג, ריצופו, או הצבת מתקן עליו, תביא לפגיעה באיטום או ביציבות המבנה, אך למותר לציין, כי אין בכך כדי להתיר לנתבעים לבצע בניה שלא בהיתר, ואין בכך כדי להביע עמדה כלשהי לעניין ניצול זכויות הבניה על ידי הנתבעים, שכן נושא זה לא נכלל בתביעה דנן.
64. גם לדרישת התובעים למתן צו כללי, המורה לנתבעים לתחזק את הגג באופן ראוי, אין בידי להיעתר. הוראות התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, ובעיקר סעיפים 2-4 לו, מחייבים כל בעל דירה לשמור על תקינות דירתו, ומטילים עליו את האחריות לתקן כל פגם בדירתו שגורם נזק לדירה אחרת או לרכוש המשותף. דרישה זו של התובעים אינה אפוא אלא, דרישה להצהרה כללית על כי על הנתבעים לקיים את הדרישה בחוק, ולכך אין מקום. לעניין זה אין לי אלא להפנות לעת"מ (מח-ים) 39597-07-11 **עדה שמיר אורביטו נ' עיריית ירושלים** (פורסם באתר נבו), שם נקבע כי: הלכה פסוקה היא שאין בית המשפט נענה לעותר המבקש סעד כוללני, היינו סעד המתייחס "למדיניות הראויה בסוג של מקרים או לדרך ההתנהגות הנדרשת בסוג של מקרים, שמספרם אינו ידוע ופרטיהם אינם ברורים, להבדיל מסעד ממוקד, המתייחס למקרה מסוים שעובדותיו ידועות וברורות" (בג"ץ 1901/94 לנדאו נ' עיריית ירושלים, פ"ד מח(4) 403, 411). כך במיוחד כאשר תוכן הסעד הנו הצהרה בדבר חובת הרשות המינהלית לציית לחוק, שהרי "הצהרה כזאת, האומרת את המובן מאליו, מיותרת לחלוטין. וכי המשיבים טוענים שהם פטורים מעולו של החוק? וכי העותרים סבורים שהצהרה של בית המשפט כי יש לקיים את החוק תוסיף לחוק תוקף או משקל? בית המשפט אינו נותן הצהרות מעין אלה, שאין בהן צורך, תועלת או כבוד". דברים אלו יפים באופן דומה גם לענייננו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

65. טענות התובעים בדבר שינוי חזות הבית המשותף כתוצאה מהגבהת המעקות ופתיחת פתחים בקירות הבית המשותף:

66. סעיף 2א לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין המצוטט לעיל (שאין חולק כי הוא חל על ענייננו) קובע: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". בחקשר לסעיף זה נפסק, כי כל פגיעה בחזותו החיצונית של הבית המשותף אינה בגדר "שימוש סביר", והיא דורשת את הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. בתוך כך נקבע, כי כל אימת שבעל דירה פורץ קיר חיצוני של הבית המשותף או משנה את חזותו, עליו לקבל את הסכמת האסיפה הכללית [ר' למשל: ע"א 515/65, רבובסקי נ' גלסברג, פד"י (2), 290, ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, פ"ד, מ(1), 724].

67. נוכח הלכות אלו, הרי שהנתבעים אינם רשאים לבצע פעולות בקירות החיצוניים של הבית המשותף, ללא שקיבלו לכך את הסכמתם של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית.

68. אשר על כן, ניתן בזה צו כנגד הנתבעים שלא לבצע שינוי בקירות הבית המשותף, ללא הסכמת הרוב כאמור. יוער, כי בסיכומיהם מדגישים הנתבעים כי הדבר מקובל עליהם וכי ממילא אין בכוונתם לבצע שינוי בקיר חיצוני, ובכלל זה בפתח היציאה לחדר המדרגות ללא הסכמת בעלי הדירות.

69. בכל הנוגע למעקות שהציבו הנתבעים בגג ולפרגולה שבנו, הרי שמאחר שהם מצויים בחזית הבית המשותף, אין ספק כי התקנתם מהווה שינוי חזיתו של הבית המשותף, והיה על הנתבעים לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות להצבתם. הסכמה כזו לא הוצגה בפניי, ולפיכך אני מורה לנתבעים להסיר את המעקות ולהשיב המצב לקדמותו, אלא אם כן יקבלו הנתבעים הסכמה של רוב באסיפה הכללית, וזאת בתוך 60 ימים מקבלת פסק הדין [לאפשרות להציג את ההסכמה בדיעבד, השווה גם לאמור בפסק הדין בע"א 93/84 קדמי נ' קוין, פד"י, מ(1), 724]. הדברים האמורים נכונים אף ביחס לפריצת חלונות בקיר חיצוני של הבית המשותף, כאמור לעיל.

70. בטרם סיום פסק הדין חשוב להוסיף, כי כל האמור בפסק דין זה, הינו בפן הקנייני של המחלוקת, וברי כי אין בכך כדי לפטור את הנתבעים מהצורך בקבלת היתר בניה כדין, ככל שהדבר דרוש על פי דיני התכנון והבניה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ה. סיכום:

71. התביעה ביחס לכל הסעדים שעניינם אופי השימוש בגג, נמחקת, כמוסבר לעיל.
72. התביעה למתן צו המצהיר, כי כל פעולת בניה בגג ובכלל זה ריצופו, או הצבה של ריהוט על הגג, או שימוש כלשהו בגג, מהווה סכנה ליציבות הבית המשותף, נדחת. כאמור לעיל, אין בכך כדי להתיר בניה בגג ללא קבלת ההסכמות הדרושות בחוק או בניגוד לדיני התכנון והבניה, ואין בכך כדי לפטור את הנתבעים מלדאוג לכך שכל פעולה שיבצעו לא תפגע בתקינות הבית המשותף.
73. ניתן בזה צו האוסר על הנתבעים לשנות את חזותו של הבית המשותף, ובכלל זה לפתוח פתחים בקירותיו החיצוניים, ללא קבלת הרוב באסיפה הכללית.
74. התביעה להסרת הפרגולה והמעקות מתקבלת, אלא אם כן יוצג הרוב הדרוש כאמור בסעיף 69 לעיל.
75. נוכח תוצאת פסק הדין, שלפיה התביעה נמחקה או נדחתה ברובה הגדול, ראוי לפסוק הוצאות משפט לטובת הנתבעים. עם זאת, בהתחשב ביחסי השכנות בבית המשותף, כמו גם לאור ההוצאות שנפסקו בעבר כנגד התובעים בגין התנהלותם במסגרת ההליכים בתיק, נראה לי לנכון להעמיד את הוצאות המשפט על הצד הנמוך. התובעים ישלמו, על כן, לנתבעים הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪.

ניתן היום כ"ז אדר א' תשע"ד, 27 פברואר 2014, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

יש חיילר

מפקח בכיר על רישום המקרקעין